

1501834-88.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... CORPUS - Penal e Processual Penal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Causa de diminuição da pena - Artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06 - Não-preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício - Ordem denegada.

1. Segundo o parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06, nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501834-88.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501834-88.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MATHEUS DE JESUS GUIDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que o réu, GABRIEL MATHEUS DE JESUS GUIDO, em hora e local descritos na inicial acusatória, trazia consigo, nas imediações de estabelecimento de ensino, para consumo de terceiros, a substância entorpecente mencionada na peça inaugural. Em razão dos fatos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Denúncia recebida à fl. 113. Audiência de instrução colhida por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares.

2. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 98/100, bem como toda a prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Para além do depoimento do GCM Victor, merece destaque a confissão do réu em audiência judicial.

3. Sem mais delongas, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base.

Considerando que um fator a ser sopesado nesta fase é a natureza e a quantidade da substância (art. 42 da Lei de Drogas), é digno de nota ressaltar que o réu, dentre a significativa pletora de entorpecentes comercializados, também portava crack, verdadeira chaga da sociedade atual, pelo seu baixo preço e altíssimo potencial viciante, alastrando-se como metástase pelas cidades brasileiras, sem perdoar pequenas urbes da periferia, como este município de Itapeacerica da Serra.

Não pode o Judiciário, pois, fazer ouvidos de mercador à estrepitosa grita social (que inclui não apenas a massa leiga e iletrada da população, mas também especialistas de alta cepa em sociologia, saúde pública e demais áreas do conhecimento suscitadas pelo fenômeno) deflagrada pela difusão do crack, devendo o disseminador da substância ser repreendido com dose de severidade acima do patamar ordinário.

Reprimenda majorada em 1/6, fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase, retrocedo a sanção ao patamar de saída, em decorrência da confissão e da menoridade relativa.

Na terceira fase, encontra-se presente a majorante do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06.

Assim o é, porque o fato foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, conforme mapa de fl. 82.

Quanto à calibragem do aumento, considerando que a qualidade de entorpecentes já foi valorada na primeira fase, de modo a evitar bis in idem contra o inculcado majoro a exprobração no patamar mínimo de 1/6, estipulando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, o réu não faz jus à minorante do art. 33, par. 4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, malgrado se trate de não reincidente, a gigantesca quantidade e diversidade de droga apreendida (um total de 303 porções de drogas diversas, cabendo enfatizar que apenas a maconha atingiu 800 gramas) faz presumir se cuidar de indivíduo dedicado a atividades criminosas habituais, em franca oposição ao "espírito" do redutor em comento, o qual veio a lume com o objetivo de estremar o pequeno traficante dos grandes barões da traficância. Em caso idêntico ao presente, o STJ assim se posicionou (grifei):

"HABEAS CORPUS - Penal e Processual Penal - Tráfico ilícito de entorpecentes - Causa de diminuição da pena - Artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06 - Não-preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício - Ordem denegada. 1. Segundo o parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06, nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. É inaplicável a minorante legal ao caso, uma vez que, embora o paciente seja primário e de bons antecedentes, ele não atende ao requisito previsto no mencionado

dispositivo atinente à vedação de se dedicar a atividade criminosa, pois restou evidenciada nos autos a prática do tráfico, em razão da grande quantidade da substância entorpecente apreendida. Precedentes do STJ.

3. Ordem denegada”.

(STJ - HC nº 111.891 - GO - 5ª T. - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - J. 06.11.2008 - DJe 24.11.2008).

Na mesma toada, decisórios do Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei):

“PENA - Fixação - Tóxicos - Causa de diminuição da reprimenda prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Grande quantidade de droga e demais circunstâncias do crime - Incidência - O mencionado parágrafo não pode ser sopesado isoladamente, sob pena de extrair do magistrado a tarefa jurisdicional de individualização da sanção penal - Causa de diminuição que deve ser analisada em consonância com os artigos 42 do mesmo diploma e 59 do Código Penal, sem o que não haverá critérios norteadores a fim de se estabelecer o "quantum" da redução - Além do mais, o transporte de mais de noventa e dois quilos de drogas é um forte indicativo de que o réu pertence à organização criminosa, pois não é crível que quantidade acentuada seja disponibilizada à terceira pessoa sem vínculos com o grupo criminoso - Inexistência de "bis in idem" - Recurso parcialmente provido”. (TJSP - Ap. nº 990.09.235.136-2 - Presidente Epitácio - 10ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida - J. 29.07.2010 - v.u).

“PENA - Fixação - Tráfico de entorpecentes - Incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 11.343/06 - Descabimento, por não se tratar de pequena e eventual traficante - Ré condenada por guardar grande quantidade de porções individualizadas da droga, o que permitiria ampla difusão, atingindo número considerável de pessoas - Apreensão, ainda, de balança de precisão e sacola contendo frascos vazios - Circunstâncias indicativas de que a agente se dedicava à atividade organizada do tráfico de entorpecentes - Recurso do Ministério Público provido para afastar a referida causa de diminuição de pena”. (TJSP - Ap. nº 990.10.093.274-8 - São Paulo - 15ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Amado de Faria Souza - J. 15.07.2010 - v.u).

É evidente que a quantidade de entorpecentes pode ser sopesada como elemento indiciário, a sinalizar envolvimento aprofundado na criminalidade, até porque seria absolutamente inusitado que um traficante de “primeira viagem” fizesse o comércio de elevado montante de drogas.

Como pontificou o TJSP na apelação criminal nº 1500859-03.2020.8.26.0628, oriunda desta Comarca:

“Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux)”.

Mesmo porque, como muito bem pontuou o Ministro Luiz Fux no julgado acima mencionado: “os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'”.

Imperativo consignar que não há duplicidade em prejuízo do requerido. Com efeito, na primeira etapa do critério trifásico fora considerada exclusivamente a natureza de um dos entorpecentes; no terceiro momento, a causa de diminuição fora rechaçada

exclusivamente em virtude da quantidade e diversidade de drogas.

Considerando que a qualidade e a quantidade de narcóticos configuram circunstâncias autônomas e independentes, não há reparo a fazer quando são manejadas em diferentes etapas da dosimetria penal. Nos moldes da jurisprudência do STF (grifei):

"Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico internacional de entorpecentes. Dosimetria da pena. Quantidade da droga. Bis in idem. Inocorrência. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. No julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que 'configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). ' 3. No caso, não é possível falar em indevido bis in idem, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida (4kg de cocaína) não foi utilizada para justificar o fator de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido". (HC nº 126.851/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJ de 19/5/15)

"Agravo regimental em habeas corpus. Precedentes. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência. Diferença entre quantidade de drogas nas fases de individualização da pena. Regimental não provido". (HC 148.333 AgR/MG. RELATOR: Ministro Dias Toffoli. DJe de 5.9.2018)

Consoante pertinentemente observou o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão de sua lavra (RHC nº 144.519/SC, DJe de 5/12/17):

"É lícito afirmar que a quantidade e a natureza da substância, como vetores independentes que são, podem ser destacados e considerados em momentos distintos da fixação da reprimenda. Bis in idem ocorreria se a mesma circunstância, quantidade ou natureza (ou mesmo ambas, em conjunto), fosse sopesada simultaneamente em mais de uma etapa. Assim, conforme ponderaram as instâncias antecedentes, a consideração da natureza da droga (cocaína) na primeira fase para majorar a pena-base e da quantidade apreendida (567 gramas) na terceira fase para dimensionar a redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 não constitui ilegalidade".

Afastada a benesse.

Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com as penas corporais aplicadas, fixo o número de dias-multa em 583. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo o dia-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

Passo a deliberar sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

Mudando o meu posicionamento, passei a entender viável a imposição legal de início de cumprimento de pena em regime inicial fechado, independentemente de singularidades do caso concreto. Explico.

É verdade que o STF já considerou inconstitucional a determinação de regime inicial

obrigatoriamente fechado (art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos), cabendo ao juiz do caso o estabelecimento do regime a partir da aferição dos elementos concretos do processo (HC 111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27.6.2012).

Todavia, não há decisão em tal sentido prolatada em sede de controle concentrado de constitucionalidade; logo, inexistente efeito vinculante a manietar os demais órgãos judiciais.

Ademais, o próprio STF, ao que parece, vem vacilando sobre o tema.

É que a 1ª Turma daquela Corte Constitucional reputou constitucional o art. 1º, par. 7º, da Lei n. 9455/97, que estabelece, como regra, cumprimento de pena em regime inicial fechado para os condenados pelo crime de tortura (HC 123316/SE, rel. Min. Marco Aurélio, 9.6.2015).

Vale ressaltar que a tortura e o tráfico de entorpecentes receberam o mesmo tratamento pelo constituinte originário (art. 5º, XLIII, CF/88).

Não há qualquer razão, portanto, para conferir ao condenado por tráfico tratamento mais benevolente do que o concedido ao apenado pelo delito de tortura -- sendo conveniente lembrar, aliás, que o crime de tortura, salvo quando resulte em morte da vítima, possui pena-base inferior ao de tráfico.

Enfim, deve ser homenageado o art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

De qualquer forma, ainda que fosse deixado de lado o dispositivo supra, é fato que qualquer outro regime não fará frente aos objetivos da prevenção e reprovação do crime (art. 59, caput, parte final, CP), em vista da gravidade em concreto do delito praticado, o que autorizou, destarte, o incremento da censura na primeira e terceira fases, além da negativa de diminuição na última etapa do trajeto censório.

Inviável falar em substituição por pena restritiva de direitos, em decorrência da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada.

4. Ante o exposto, declaro o réu GABRIEL MATHEUS DE JESUS GUIDO incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa cada, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

5. O réu, que respondeu ao feito preso, assim deve permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que o exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial diverso do aberto pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorrível. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

"O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade"

(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

6. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

7. Custas na forma da legislação estadual.

8. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

9. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

P.R.I.C.

Itapeccerica da Serra, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA